

1500327-48.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... onde tem um conhecido ponto de tráfico de drogas. O policial afirma que bem no ponto de tráfico de drogas em comento, estava um indivíduo, sozinho, o qual, ao visualizar a aproximação da viatura, saiu correndo em desabalada carreira. O policial afirma que fez o acompanhamento com a viatura, sendo que na Rua Neusa Maria Mendes Tonin, o indivíduo em comento, ora indiciado, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500327-48.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2059802/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 23365550 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 687/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2059802 - 02º D.P. PIRACICABA, 687/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2059802/2022 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO CÉSAR NEVES CAVALHEIRO

Réu Preso

Contr. nº 2022/000270

Aos 20 de junho de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu AUGUSTO CESAR NEVES CAVALHEIRO (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa da Dra. KAREEN PATRÍCIA BANDEIRA PEREIRA FERREIRA. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM Edivaldo da Silva Santos e PM DOUGLAS WALTER RADESCHI DE TOLEDO.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa. Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente a comum (PM Douglas), após a de defesa (PM Edivaldo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor foi dito que desistia da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Edivaldo, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). AUGUSTO CESARNEVES CAVALHEIRO, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 3 de março de 2022, por volta das 19h30, na Rua Pascoal Barsotini, n.º 100, bairro Agua Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 125(125) porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas, com peso líquido de 29,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 80/82). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitativa foi confirmada nos autos pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; fotografia de fls. 10 e laudo a fls. 93/95. Da mesma forma, comprovada a autoria delitativa. De fato, o policial relatou, na fase informativa (fls. 02), que "Estava em patrulhamento ostensivo de rotina pelo Bairro Jardim Oriente. O policial afirma que, em determinado momento, passou pela Rua Paschoal Bersotini, onde tem um conhecido ponto de tráfico de drogas. O policial afirma que bem no ponto de tráfico de drogas em comento, estava um indivíduo, sozinho, o qual, ao visualizar a aproximação da viatura, saiu correndo em desabalada carreira. O policial afirma que fez o acompanhamento com a viatura, sendo que na Rua Neusa Maria Mendes Tonin, o indivíduo em comento, ora indiciado, se escondeu atrás de um veículo que estava estacionado na via. Segundo o policial, ao se aproximar e desembarcar da viatura, o indiciado se levantou, dispensou um objeto ao chão e voltou a correr. O policial afirma perseguiu o indiciado a pé e o abordou logo na sequência, na mesma via. Em revista pessoal, na posse do indiciado foi localizado dinheiro em espécie. O policial afirma ter retornado ao local da dispensa do objeto e verificou tratar-se de cento e vinte e cinco porções de cocaína. Por fim, o policial afirma que o indiciado resistiu à prisão e inflamou a população das imediações, tendo que utilizar algemas para a detenção". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o local é conhecido ponto de drogas e várias prisões são efetuadas ali. Ele falou no local que estava vendendo drogas desde às 18:00hs e iria ficar no ponto até 24:00hs e que iria receber quantia em dinheiro para tal atividade. seu companheiro de farda corroborou as informações pelo seu companheiro de farda. A destinação das drogas para o comércio ilegal é evidenciada pelas circunstâncias da prisão, estando o denunciado em conhecido ponto de tráfico, na posse de grande quantidade de droga dividida em pequenas porções, prontas para a comercialização, além do dinheiro, produto do comércio ilícito. Outrossim, informalmente, o réu confessou e deu inclusive detalhes do seu "turno". Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denuncia. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico (certidão a fls. 41/42 e FA a fls. 49), razão pela qual não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, não somente pelo acima descrito, como, também, porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros

crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

AUGUSTO CESAR NEVES CAVALHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 3 de março de 2022, por volta das 19h30, na Rua Pascoal Barsotini n.º 100, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 125 porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas, com peso líquido de 29,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; fotografia de fls. 10; laudo constatação de fls. 15/17).

Narra, a denúncia que o acusado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, trazendo consigo as drogas supra mencionadas. Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo de rotina no local (conhecido ponto de tráfico), quando, ao serem avistados por Augusto, este saiu correndo.

A viatura policial fez o acompanhamento até que, na rua Neusa Maria Mendes Tonin, o acusado se escondeu atrás de um veículo estacionado. Os policiais desembarcaram da viatura, ocasião em que Augusto se levantou, dispensou um objeto no chão e voltou a correr, sendo, todavia, perseguido, alcançado e abordado pelos policiais.

Ao ser revistado, os policiais encontraram com o acusado R\$20,00 em dinheiro, produto do comércio ilícito. Recolhido o material dispensado por Augusto, constatou-se tratar-se das 125 cápsulas contendo cocaína, sendo ele preso em flagrante delito.

Conclui a denúncia que a destinação das drogas para o comércio ilegal foi evidenciada pelas circunstâncias da prisão, estando o acusado em conhecido ponto de tráfico, na posse de grande quantidade de droga, além da forma de acondicionamento, em pequenas porções, prontas para a comercialização, e portando dinheiro, produto do comércio ilícito.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 102). Defesa preliminar apresentada às fls. 106/107. Após, a denúncia foi recebida (fls. 108) e o réu foi citado às fls. 119.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pleiteou a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, fotografia de fls. 10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 93/95, ambos com resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu permaneceu silente.

Interrogado em juízo (gravação), negou o tráfico, dizendo que, no dia dos fatos, recebeu dinheiro de venda de reciclagem. Foi até o local dos fatos e comprou dois pinos de cocaína. Sobrou R\$ 20,00 do dinheiro que possuía. Logo que recebeu as

drogas, os policiais se aproximaram. O traficante fugiu e não foi abordado. Ficou parado e ali mesmo foi abordado pelos militares. Os policiais queriam que lhes fornecesse a identidade do traficante que fugiu. Como não sabia quem era ele, acabou sendo preso e levado à delegacia. Somente depois que foi preso, ficou sabendo que haviam intrujado 125 porções de cocaína nele. Já traficou no passado, mas havia parado com essa atividade.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Douglas Walter Radeschi de Toledo declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Oriente quando viram o réu sozinho parado no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga, correndo a pé sentido a uma praça existente nas proximidades. Efetuaram o acompanhamento com a viatura e notaram quando ele se escondeu atrás de um veículo parado na Rua Neusa Maria Mendes Tonin. Ao se aproximarem a pé para efetuarem a abordagem, o acusado se levantou, dispensou uma sacola plástica ao solo e tentou fugir novamente correndo a pé, mas foi abordado poucos metros à frente. Na revista pessoal, encontraram dinheiro em notas trocadas na posse dele. Retornando ao local onde ele havia dispensado a sacola momentos antes, constataram que se tratavam de 125 porções de cocaína. O réu admitiu que estava vendendo droga naquele local desde as 18 horas e informou que iria ficar ali até a meia noite, pelo que iria receber R\$ 50,00 a cada vinte porções que vendesse. Ele não aparentava estar sob efeito de drogas. Esclareceu, por fim, que o acusado resistiu à prisão e inflamou a população das imediações, sendo necessário o uso de força física moderada e algemas para contê-lo.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e nesta audiência (gravação) pelo policial militar Edivaldo da Silva Santos.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que não tinha qualquer desavença com eles anteriormente. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo 125 porções de cocaína, para fins de mercancia e consumo de terceiros.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as drogas estavam na sua posse e foram dispensadas ao solo antes da abordagem.

Confirma a prática delitativa o fato de o réu ter sido flagrado parado em local já conhecido como ponto de venda de drogas e ter agido de forma suspeita ao avistar a viatura policial, empreendendo fuga para tentar evitar a abordagem.

Por outro lado, era expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, incompatível com a situação de mero usuário.

Some-se a isso, o fato de as drogas estarem fracionadas e embaladas em porções individuais, como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 10)

Não bastasse, com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 20,00 em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, presumindo-se tratar de produto das vendas realizadas.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos

policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

O réu possui maus antecedentes (em razão de condenação definitiva pelo mesmo crime, conforme consta da certidão de fls. 41/42 - processo nº 0005001-20.2013.8.26.0451 da 2ª Vara Criminal local, cuja pena foi julgada extinta em 07/05/2015).

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, registrando-se que a quantidade de drogas, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo as penas-base 1/6 acima do mínimo, o

que perfaz cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não se faz presente nenhuma circunstância atenuante.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, que, no caso, é específica (conforme certidão de fls. 41/42, complementada pelas fls. 90 da F.A., o réu sofreu condenação definitiva por tráfico de drogas, no processo nº 0000022-22.2014.8.26.0599 dessa 1ª Vara Criminal, cuja pena foi julgada extinta em 23/02/2022).

Dessa forma, aumento a reprimenda em 1/6, perfazendo seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, os maus antecedentes e a reincidência, que, no caso, é específica, impedem a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Tais circunstâncias impõem a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, estes também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada.

De fato, nesse contexto em que o réu possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, o que indica que vem reiterando na prática do crime em questão, o qual traz graves consequências para sociedade, fomentando a prática de vários outros crimes, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício, não há possibilidade de se conceder qualquer benesse ao acusado.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação mantida - Pena-base majorada em ½ (metade) - Manutenção - Proporcionalidade - Três maus antecedentes - Caráter perpétuo de condenações transitadas em julgado - A depuração apenas se dá em relação à reincidência (CP,

art. 64, I) - Quantidade elevada de "maconha" e apreensão de cocaína, com potencialidade lesiva significativa - Causa de diminuição de pena - Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - Impossibilidade - Maus antecedentes e dedicação às atividades criminosas - Regime inicial fechado mantido - Art. 33, § 3º, do CP - Recurso não provido." (TJSP - Apelação 0000940-98.2015.8.26.0111. 9ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Alberto Anderson Filho - j. 18/08/2017) -g.n.

"Apelação Criminal. Tráfico. Apreensão de 312 gramas de maconha, no interior de estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil, demonstradas pelo acervo coligido - Depoimentos de agentes de segurança penitenciária, seguros e sem contradições, cujo teor foi corroborado pela confissão judicial - Crime caracterizado que afasta a pretensão desclassificatória - Condição de usuária (sequer aventada pela ré) que não impede a prática do tráfico ilícito nem é suficiente para descaracterizá-lo - Majorante configurada (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional) - Dosimetria - Reincidência (específica) e gravidade concreta do delito que obstam a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime prisional fechado para o início da expiação - Condenação confirmada em 2º grau que exige a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação - Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - Apelo defensivo, não provido, com determinação." (TJSP - Apelação 0016048-25.2016.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) -g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e os maus antecedentes e aumentar a pena do crime por essas razões ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro, por fim, que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas três meses e dezoito dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime. Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu AUGUSTO CESAR NEVES CAVALHEIRO a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu ostenta maus antecedentes e reincidência, ambos em razão de condenações definitivas pela prática de tráfico de drogas, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa e demonstra maior periculosidade e seu desprezo pela sociedade. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.